

<입문-제7장.행정의 실효성 확보수단.제5절 즉시강제>

I. 행정상 즉시강제의 의의

1. 개념

- 즉시강제란 행정목적 달성을 위해 급박한 상황에서 미리 의무를 명할 시간적 여유가 없거나, 또는 의무를 명하는 것만으로는 그 목적을 달성하기 곤란할 때, 행정청이 직접 국민의 신체나 재산에 실력을 행사하여 행정상 필요한 상태를 실현하는 행정작용을 말한다. 이는 다른 행정강제 수단과는 달리 의무의 존재를 전제로 하지 않거나 의무 부과 절차를 생략하고 곧바로 실력을 행사한다는 특징이 있다.

2. 구별 개념

(1) 행정상 강제집행과의 구별

- 행정상 강제집행(대집행, 직접강제, 강제징수)은 이미 발생한 의무의 불이행을 전제로 하여 장래의 의무 이행을 확보하기 위해 발동되는 행위이다. 반면, 즉시강제는 의무 불이행을 전제로 하지 않고 급박한 상황에서 행정의 즉각적인 필요에 의해 발동되는 조치라는 점에서 가장 명확하게 구별된다. 즉시강제는 행정목적 달성을 위해 응급적인 조치를 취하는 성격을 가진다.

(2) 행정조사와의 구별

- 행정조사(검사, 질문)는 행정주체가 정책을 수립하거나 직무를 수행하는 데 필요한 자료나 정보를 수집하기 위한 사실 행위이다. 반면, 즉시강제는 위험 제거와 같은 행정목적 직접적으로 실현하기 위해 국민의 신체나 재산에 실력을 행사하는 강제적인 공권력 행사라는 점에서 그 목적과 성격이 다르다.

3. 법적 성질

- 즉시강제는 국민의 신체와 재산에 직접적인 영향을 미치는 공권력의 행사이므로, 행정행위 또는 행정작용으로 본다. 다만, 의무 부과 없이 곧바로 실력을 행사하는 사실 행위적 성격도 가지고 있어 법적 성질에 대해 다툼이 있다. 통설은 권력적 사실 행위로 보거나, 강제 처분의 일종으로 보아 처분성이 인정되는 것으로 해석한다. 처분성이 인정될 경우, 국민은 그 위법성에 대해 항고소송(특히 무효확인소송)을 제기하여 구제받을 수 있다.

4. 행정상 즉시강제의 근거

- 즉시강제는 국민의 기본권을 중대하게 침해할 가능성이 높으므로, 반드시 법률의 근거에 의해서만 발동되어야 한다는 법률유보의 원칙이 철저히 적용된다. 즉시강제에 관한 일반법은 없으며, 개별 법률에 근거하여 행해진다. 예를 들어 경찰관직무집행법상의 보호조치, 위험 발생 방지 조치 등이 있다. 이 경우, 국민의 권리 침해를 최소화하기 위해 비례의 원칙(최소침해의 원칙)이 특히 중요하게 요구된다.

II. 행정상 즉시강제의 종류

- 즉시강제는 그 대상이 되는 객체에 따라 대인적 강제, 대물적 강제, 대가택 강제로 분류된다.

1. 대인적 강제

- 대인적 강제란 사람의 신체나 행동의 자유에 실력을 행사하여 행정목적 달성을 즉시강제를 말한다. 이는 국민의 기본권 중에서도 신체의 자유를 직접적으로 제한하므로 가장 엄격한 법적 통제가 필요하다. 예를 들어 감염병 예방을 위한 환자의 강제 격리 또는 수용, 경찰관직무집행법상의 보호조치(술에 취하여 심신 상실 상태에 있는 자 등의 보호) 등을 들 수 있다.

2. 대물적 강제

- 대물적 강제란 사람의 소유물이나 기타 재산에 실력을 행사하여 행정목적 달성을 즉시강제를 말한다. 이는 주로 물건이 초래하는 위험을 제거하거나 손해를 예방하는 것을 목적으로 한다. 예를 들어 화재 발생 시 소방관이 주변 건물이나 물건을 파괴하여 불길의 확산을 막는 소방상의 조치, 교통 안전을 위해 위험한 물건을 일시적으로 수거하는 행위 등이 있다.

3. 대가택 강제

- 대가택 강제란 행정청이 국민의 주거지나 기타 사적인 공간(가택)에 출입하여 행정상 필요한 조치를 취하는 즉시강제를 말한다. 이는 주거의 자유를 침해하는 행위이므로 역시 엄격한 요건 하에서만 허용된다. 예를 들어 감염병 확산을 막기 위해 방역 당국이 감염 우려가 있는 가택에 강제 진입하여 소독을 실시하거나, 범죄 수사를 위해 법원의 영장 없이 긴급 상황에서 건물에 진입하는 행위 등이 있으나, 주거의 자유 보호를 위해 매우 제한적으로 인정된다.

III. 결론

- 즉시강제는 급박성과 보충성을 특징으로 하는 행정강제 수단으로, 의무의 존재를 전제로 하지 않고 곧바로 국민의 신체나 재산에 실력을 행사하는 조치이다. 이는 처분성이 인정되어 국민은 항고소송을 통해 권리 구제를 받을 수 있으며, 국민의 기본권 침해 가능성이 높으므로 반드시 개별 법률의 명확한 근거와 비례의 원칙을 엄격히 준수하여 행사되어야 한다.